

1501965-76.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... no sentido de evidenciarem ter a acusada praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente.

Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501965-76.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501965-76.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELE CORDOVA NEGREIROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

GABRIELE CORDOVA NEGREIROS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 61, inc. II, "j", do Cód. Penal, porque no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 14h10min, na Rua Dom Pedro I, 711, nesta cidade e comarca, guardava e mantinha em depósito, para futura entrega a terceiros, três tijolos e oito porções de "maconha", pesando 2288,12g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar um aparelho celular.

Policiais militares, com informações de populares sobre a prática do comércio ilícito, efetivaram diligências no imóvel da ré, que franqueou a entrada, e localizaram, no guarda-roupa do dormitório, as porções do entorpecente e o celular. Oferecida a denúncia foi a ré notificada e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Após, foi interrogada a ré.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do delito, requereu a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição da ré sustentando, em suma, insuficiência de prova a delinear o crime.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, ante o estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes no local, e, ao depois, ante autorização da ré, que, inclusive, acompanhou toda a diligência de busca.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando-se a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância da denunciada, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial.

Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.035.493/AM, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.06.2022).

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, que revela o encontro do entorpecente e do celular em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 18/21 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 69/71, concludentes no sentido de se tratar de

Tetrahidrocannabinol - THC, a substância encontrada.

O aparelho celular foi vistoriado às fls. 195/207, constatando-se diálogos e imagens relativos à traficância.

Na fase policial disse a ré ter conhecido "André" em grupo da rede social "Facebook", denominado "Legaliza RP", destinado à troca de mensagens relativas à comercialização de tóxico, tendo sido por ele contratada para guardar o entorpecente na residência, recebendo R\$ 1.000,00 pelo serviço.

Em Juízo, reiterou a ré a confissão, mas receberia R\$ 2.000,00 pela guarda do tóxico.

A confissão quanto à autoria foi revestida de caráter absoluto ante a fala dos policiais.

Vejamos.

Contam os agentes terem informações de populares propiciado diligências no imóvel da ré, que permitiu a entrada no local, localizando-se, no interior do guarda-roupa

do dormitório, as porções da droga e o celular. Para tais testemunhas, admitiu a denunciada ter sido contratada, por indivíduo desconhecido, em rede social, para guarda do entorpecente.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais militares incriminar o réu ou forjar o crime, até porque, trata-se de pessoa desconhecida.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira da ré, que não comprovou relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a negociação ou guarda do produto, medida impositiva, na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter a acusada praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente.

Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso” (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Por fim, vale observar que as finalidades da agravante prevista no art. 61, inc. II, “j”, do Cód. Penal, são a proteção da sociedade, bem como punição mais rigorosa da conduta de quem, valendo-se das facilidades do contexto calamitoso, pratica delitos.

In casu, não havendo nexos causal entre a situação de pandemia e a conduta da ré, é

de rigor o afastamento da mencionada agravante. Nesse sentido: “Primeiramente, faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19.” (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. Andrade Sampaio, 12.02.2021).

Convencida da responsabilidade penal da ré, passo a individualizar as penas. Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a elevada quantidade de droga.

Verificada a confissão da autoria, incide a circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, “d”, do Cód. Penal, razão pela qual reduzo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter a ré respondido encarcerada à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: “(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença”. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: “Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque a quantidade de drogas apreendidas indica dedicar-se a ré à atividades criminosas, posto inexistir comprovação de atual relação de emprego.

Neste sentido a doutrina: “de mais a mais, tem-se decidido que apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil

a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena.” (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius, Lei de Drogas: aspectos penais processuais. 2021, p. 107).

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica da acusada (art. 43, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno GABRIELE CORDOVA NEGREIROS, R.G. n.º 54.768.192, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não poderá apelar a ré desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento da ré do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se a ré no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflictivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação da delinquente.

Observados o art. 63 da Lei n.º 11.343/06 e o art. 91, inc. II, “b”, do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do celular (fls. 14/15), pois obtidos em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei n.º 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para o fim de destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei n.º 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA